

1500172-11.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... imputa aos réus a prática do delito de tráfico de drogas majorado, a qual merece parcial procedência porquanto o acervo probatório reunido sustenta a versão acusatória no tocante ao crime de tráfico de drogas, ficando, contudo, afastada a causa de aumento de pena.

Com efeito, a materialidade delitativa encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/16; auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500172-11.2022.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-11.2022.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2108390/2022 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 24439470 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2108390 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 55/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON MENDES CHAVES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

MARCIO DA SILVA COSTA, NÍCOLAS DE LIMA NUNES e WASHINGTON MENDES CHAVES, qualificados respectivamente a fls. 4, 5 e 6, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, porque segundo a denúncia no dia 20 de abril de 2022, por volta de 8 horas, na Rodovia Mello Peixoto, n. 378, Vila Musa - nesta cidade e Comarca de Ourinhos, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, transportavam e traziam consigo, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, para fins de tráfico, 304,087 kg de

maconha, separadas em 298 embalagens azuis (203.699 gramas) e 146 embalagens amarelas (100.388 gramas), somando o total de 444 tijolos. Os réus foram notificados pessoalmente e apresentaram defesa prévia: Nicolas à fls. 281/284; Márcio às fls. 292/295 e Washington às fls. 316/318. A denúncia foi recebida em 27 de julho 2022 pela decisão proferida às fls. 555/560, após o que os réus foram regularmente citados. Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, uma defensiva e interrogados os réus, seguindo-se pelos debates, nos quais o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa do acusado Washington, por seu turno, postulou pelo afastamento da causa de aumento de pena do tráfico entre Estados da Federação e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e demais benefícios legais (fls. 621/627). Já a Defesa do acusado Nicolas requereu a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, havendo condenação, postulou-se pela aplicação da pena base no patamar mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena (fls. 638/645). Por derradeiro, a Defesa do acusado Márcio, requereu igualmente o afastamento da causa de aumento de pena e fixação da pena no patamar mínimo legal. Requereu ainda a restituição do veículo apreendido (fls. 638/645).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, tendo as questões prejudiciais de mérito sido abordadas e afastadas conforme decisão proferida às fls. 555/560, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa aos réus a prática do delito de tráfico de drogas majorado, a qual merece parcial procedência porquanto o acervo probatório reunido sustenta a versão acusatória no tocante ao crime de tráfico de drogas, ficando, contudo, afastada a causa de aumento de pena.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/16; auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 21/31 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 269/274.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, os acusados optaram pelo direito constitucional ao silêncio.

Em sede de interrogatório judicial, o réu Marcio da Silva Costa confessou a prática do tráfico de drogas, admitindo estar realizando o transporte de drogas no veículo Gol descrito na exordial acusatória. Narrou ter sido contatado por pessoa não identificada para realizar o transporte de 100 kg de maconha, do município de Ourinhos/SP até o município de Santa Cruz do Rio Pardo. Declarou que foi orientado a receber o entorpecente em um ponto da estrada que dá acesso ao Clube Diacuí, para onde se deslocou e acompanhou o carregamento do veículo com o entorpecente, após o que retornou à Rodovia para seguir viagem, no entanto acabou sofrendo a abordagem policial. Ato contínuo, a mesma equipe policial realizou a abordagem de um veículo Siena que passava pela rodovia, dentro do qual também foram localizados entorpecente, no entanto negou qualquer relação com tais drogas.

Do mesmo modo o réu Washington Mendes Chaves admitiu a prática criminosa, confessando que estava conduzindo o veículo Siena, o qual estava carregado de entorpecentes e foi abordado pela polícia militar na ocasião dos fatos. Narrou que ter recebido uma proposta para realizar o transporte do entorpecente até a cidade de Botucatu/SP, pelo que receberia o valor de R\$ 800,00. No mesmo dia acabou encontrando o corréu Nicolas e comentou que iria viajar para Ourinhos, oportunidade em que ele pediu uma carona, alegando que pretendia visitar a avó. Combinaram que saíram pela madrugada e que chegando em Ourinhos o interrogando deixaria Nicolas na casa dos avós dele. No dia dos fatos, pegou o veículo Siena, pertencente ao seu

pai, que estava guardado na garagem do seu apartamento, sem a autorização dele, passou pegar Nicolas e seguiu viagem para Ourinhos. Chegando em Ourinhos decidiu passar para pegar as drogas antes de deixar Nicolas na casa da avó dele, pois estava atrasado, no entanto salientou que Nicolas não sabia nada sobre o entorpecente. Disse que foi até o local combinado e lá o veículo foi carregado com os entorpecentes, após o que acabou sofrendo a abordagem policial. Ressaltou que ao ser abordado notou que havia outro veículo sofrendo abordagem policial, no entanto negou qualquer relação com ele. Finalmente negou ter ido para o Estado do Paraná na data dos fatos.

Por fim, o réu Nicolas de Lima Nunes negou a prática delitiva, salientando que apenas pegou uma carona na viagem de Bauru/SP até Ourinhos, realizada pelo corréu Washington no veículo Siena, porém ressaltou que não tinha ciência sobre o transporte ilegal das drogas. Narrou ter encontrado ocasionalmente Washington na véspera do fato, contando que já o conhecia desde a infância, oportunidade na qual Washington comentou que iria para Ourinhos e nesse momento acabou pedindo uma carona a ele para visitar os avós que residem na referida cidade. Disse que saíram de Bauru durante a madrugada e, ao chegarem à Ourinhos Washington acabou passando pela primeira entrada da cidade, entrada esta que daria acesso a casa de seus avós, e seguiu para outro local, até que próximo à divisa do Estado Washington parou o veículo Siena próximo de outro carro que estava parado no acostamento. Na sequência Washington desembarcou, abriu o porta malas do carro e, após algum tempo, retornou para dentro do veículo novamente e seguiu com o veículo no sentido da rodovia, onde logo em seguida acabaram sofrendo a abordagem policial. Disse que a todo momento permaneceu dentro do carro sem saber o que estava acontecendo, porém ciente de que alguma coisa estranha estava ocorrendo. Afirmou que chegou a perguntar para Washington sobre o que estaria ocorrendo, porém ele se limitou a dizer que logo iria levar o interrogando até a casa de seus avós, sem esclarecer, no entanto, o que eles estavam fazendo naquele local. Informou que a abordagem policial foi rápida, tendo os policiais seguido imediatamente em direção ao carro e já dado voz de prisão aos abordados. Disse que somente tomou conhecimento da existência das drogas no veículo quando já estava na Delpol. Salientou, por fim, que o dinheiro apreendido em sua posse era destinado ao auxílio que prestaria aos avós, negando ter ido para o Estado do Paraná no dia dos fatos.

Por sua vez, as testemunhas policiais militares Luiz Eduardo Ferreira da Silva e Murilo Colombo Nantes relataram no inquisitivo que de posse de informações de que Marcio, vulgo "Cocão", já conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, iria ao Estado do Paraná buscar uma grande quantidade de drogas na companhia de outros dois indivíduos, utilizando o veículo Vw/Gol de placas MDW7C72 e seus comparsas com um veículo Fiat/Siena de cor prata, o que ocorreria entre 06h00min e 08h00min. Diante do recebimento dessas informações detalhadas, as equipes desencadearam uma operação a fim de averiguar a veracidade da denúncia, tendo as equipes táticas se posicionado na rua Onofre Alves Moreira, Pacheco Chaves, paralela à rodovia Mello Peixoto, por onde possivelmente os veículos retornariam e por volta das 06h40min, os veículos descritos na denúncia passaram pela rodovia Mello Peixoto no sentido Paraná-Ourinhos, e quando chegaram próximo ao km 378, entre os trevos do Pacheco Chaves e Jardim Itamaraty, foram abordados simultaneamente, sendo que o veículo Gol era conduzido por Márcio e o veículo Siena conduzido por Washington e no banco do passageiro Nicolas. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus, entretanto, no interior dos veículos, nos bancos traseiros e porta-malas, havia grande quantidade de "tijolos" de maconha, que totalizaram dentro do veículo Fiat/Siena havia 298 "tijolos" de maconha embaladas em plástico da cor azul e no veículo VW/Gol 146 "tijolos" da referida droga. Já no interior de uma pochete de propriedade de Nicolas havia R\$ 1707,00 (mil e setecentos e sete reais), e no interior da carteira de propriedade de Marcio o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Além desses valores foram apreendidos cinco aparelhos celulares.

Durante a dilação probatória, os policiais repetiram a narrativa anterior, relatando que o réu Marcio já era conhecido pela prática do tráfico em razão de prisão anterior, na qual estava na posse de expressiva quantidade de crack e

pistola 9 milímetros. No dia dos fatos, aportaram denúncias à corporação dando conta de que Marcio, acompanhado de dois indivíduos, iriam até o Estado do Paraná para comprar grande quantidade de drogas e que de lá retornariam entre 6 e 8 da manhã. Nessa empreitada, o réu Márcio utilizaria o veículo dele, modelo Gol, de cor preta e que os dois indivíduos que o acompanhavam estariam em um Siena de cor prata. Diante disso, no horário relatado pela denúncia, os policiais estacionaram a viatura paralela à rodovia Melo Peixoto, de onde conseguiam visualizar os veículos que passavam pela rodovia, então quando o veículo Gol com as características informadas passou pelo local, seguido de um veículo Siena, realizaram a abordagem de ambos simultaneamente. Disseram que dentro do veículo Gol estava apenas o réu Márcio, enquanto que no veículo Siena estavam os réus Washington, na condução do carro, e Nicolas, no banco do passageiro. Os três foram submetidos a revista pessoal, sendo localizado o valor de R\$ 1.707,00 na pochete de Nicolas e o montante de R\$ 400,00 com Márcio. Já na busca veicular, foi possível visualizar grande quantidade de drogas, tanto no banco do passageiro, como no porta malas dos dois veículos. Questionados sobre os entorpecentes, Washington e Nicolas não quiseram se manifestar, enquanto Márcio assumiu a propriedade, asseverando ter pago R\$ 900,00 por cada "tijolo", porém afirmou que adiantou apenas o montante de R\$ 30.000,00 pela compra, sem, contudo, esclarecer de quem ou de qual cidade havia adquirido a substância ilícita. Aclararam que, no momento da abordagem, Márcio não conversou com os outros dois réus, mas posteriormente sim. Declararam que não se têm informações sobre envolvimento dos réus Washington e Nicolas com o crime organizado, já quanto a Marcio, ostenta tatuagem com a inscrição "PCC". Finalmente a testemunha defensiva Anderson Dantas Moura nada esclareceu sobre os fatos, apenas informou que Nicolas trabalha com o pai em uma empresa no setor de entregas e tem três filhos menores de idade.

Este é, em síntese, o conjunto probatório.

Cabe anotar quanto à tipicidade da conduta, que o crime de tráfico de drogas, prescrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, caracteriza-se em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo.

Desse contexto, percebe-se que a conduta dos denunciados enquadra-se no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, na modalidade de transportar drogas. Configurado, portanto, o tráfico de drogas.

Nessa esteira, de acordo com os depoimentos uníssonos e harmônicos entre si, prestados pelos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, a corporação militar recebeu denúncia no sentido de que o réu Márcio, já conhecido no meio policial pela prática de crimes e envolvimento com organização criminosa, realizaria o transporte de grande quantidade de drogas na data dos fatos utilizando o seu veículo, um Gol de cor preta, e nessa empreitada seria acompanhado de dois indivíduos, que utilizariam um veículo modelo Siena, de cor prata. Referida delação ainda trazia a informação de que o entorpecente seria retirado no Estado do Paraná, e para o retorno, os envolvidos utilizariam a rodovia Melo Peixoto que liga os dois Estados. Diante da riqueza de detalhes da delação apócrifa, os policiais decidiram averiguar sua veracidade, posicionando-se em via marginal à rodovia de onde os veículos que passavam pelo local pudessem ser vistos, e no horário relatado, avistou-se um veículo Gol de cor preta seguido de um Siena de cor prata, os quais foram imediatamente abordados pela equipe policial, que confirmou que o réu Márcio conduzia o veículo Gol, e no veículo Siena foram identificados os réus Washington e Nicolas. Na revista pessoal aos réus, foi localizado quantia em dinheiro na posse do réu Nicolas e de Márcio. Já a revista veicular revelou a existência de 298 "tijolos" de maconha no interior do veículo Siena, espalhados em seu interior e porta malas e no Gol, 146 "tijolos" do mesmo entorpecente, que totalizaram 304.087 quilogramas de maconha, confirmando-se assim os termos da informação privilegiada recebida.

Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Outrossim, o relato dos militares restou corroborado pela confissão espontânea do correus Washington e Márcio, os quais admitiram em juízo o transporte ilegal das drogas.

Já o corréu Nicolas, por sua vez, negou qualquer envolvimento com as drogas, sustentando a versão de que apenas pegou uma carona com Washington e que desconhecia o objetivo da viagem do amigo.

Tal versão, no entanto, mostrou-se frágil e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Além disso, as circunstâncias que envolveram a viagem realizada por eles evidenciam que Nicolas, ao menos, agiu com dolo eventual, de maneira que eventual ignorância voluntária sobre o objetivo da viagem e quanto a sua ilicitude não o exime da responsabilidade pela prática do delito, eis que anuiu com a produção do resultado, o qual tinha plenas condições de prever.

No dolo eventual o agente, sabendo ou suspeitando fortemente que está envolvido em negócios escusos ou ilícitos, e, portanto, prevendo o resultado lesivo de sua conduta, toma medidas para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transações realizadas para um intuito criminoso, não se importando com o resultado.

Nesse contexto nota-se que os réus informaram que saíram de Bauru no meio da madrugada e que chegaram à cidade de Ourinhos antes das 6:00 hrs, no entanto nenhum dos dois tinha qualquer compromisso na cidade que justificasse a necessidade de chegar ao destino final tão cedo. Além disso, observa-se que Nicolas em nenhum momento se preocupou em perguntar o motivo da viagem de Washington até a cidade de Ourinhos/SP, mesmo sabendo que ele não tem parentes, amigos ou trabalho no município.

Portanto, o que se observa é que a versão trazida pelo denunciado, no sentido de que desconhecia o intuito da viagem não é verossímil. Não fosse isso, é certo que, pelas circunstâncias dos autos, possuía a capacidade para perceber a ilicitude da conduta do colega, de modo que poderia agir de forma diversa, mas optou pelo ilícito, embargando na viagem espúria.

Desse modo, resta caracterizado o dolo para o delito de tráfico de drogas.

Verifica-se, ainda, que os três réus sustentaram versão única, no sentido de que não participavam da mesma empreitada criminosa, afirmando que a abordagem dos veículos ocorreu de maneira aleatória pelos policiais militares, no entanto, ao defenderem essa versão acabaram caindo em contradição e corroborando a prova acusatória, porquanto confirmaram que os veículos não foram abordados ao mero acaso pelos policiais militares, mas que foram alvo de abordagem específica pelas equipes que realizavam a operação naquela data.

Além do mais, embora o réu Márcio tenha negado relação com o município de Bauru, onde os corréus Washington e Nicolas residem, vem sendo defendido por profissional daquela localidade, possuindo uma irmã residente no referido município, contando ainda com apontamento datado do ano de 2008, junto à 3ª Vara Criminal da Comarca de Bauru, como se vê à fl. 87, circunstâncias que aliadas aos demais elementos probatórios já ressaltados, indicam peremptoriamente o elo entre a ação criminosa dos réus para o cometimento do crime imputado.

Quanto à causa de aumento de pena, muito embora a delação apócrifa que aportou à corporação militar trouxesse a notícia de que o entorpecente traficado pelos réus tinha origem no Estado do Paraná, o que configuraria a majorante em tela, tal circunstância não restou demonstrada pelos elementos probatórios produzidos em juízo, de modo que não sendo possível obter um juízo de certeza sobre a efetiva existência do tráfico entre Estados da Federação, razão porque acolho as manifestações defensivas afastando a majorante.

Por derradeiro, no tocante aos veículos apreendidos nos autos (FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX, placas FQV1C08 e VW/GOL SPECIAL, placas MDW7C72 C - fl. 32), alinhando-me ao entendimento da Suprema Corte, que modificou o posicionamento a respeito do tema, conforme RE 638491 em repercussão geral, é caso de decretação da perda do veículo. Vejamos a ementa do decisor.

"O Tribunal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal", vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, em compromisso na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Falou, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17/5/2017".

Logo, independente da prova do uso habitual dos veículos pelos réus na prática da traficância, deve ser decretado o perdimento.

Não obstante, restou inequívoca a utilização dos veículos para a prática criminosa, diante das circunstâncias do caso, nas quais foram apreendidas as enormes quantidades de substâncias ilícitas em seu interior, cujo transporte era realizado entre os Estados da Federação, conforme reconhecido nos autos, caracterizando o uso ilegal.

Cabe anotar, ainda, que muito embora tenha havido pedido de restituição do veículo Fiat Siena pela proprietária (em apenso 3179-13.2022), observa-se que esta é genitora do acusado Washington, ao passo que o pedido em tela somente aportou aos autos após cinco meses da apreensão veicular, denotando-se claramente que não era a requerente quem tinha a efetiva posse e o uso do veículo, do contrário, já teria manejado o pedido. Outrossim, a alegação de que possui renda lícita, do que decorre a propriedade do bem não restou categoricamente comprovada apenas através das fotografias da suposta atividade laboral praticada, pelo que fica indeferido o pedido em apenso, certificando-se nele o teor desta decisão.

O mesmo se dá quanto ao pedido de restituição feito no bojo das alegações finais pelo réu Márcio, porquanto o veículo encontra-se em nome de terceira pessoa, que até o momento não fez qualquer pedido de restituição, concluindo-se que estava na

posse do réu, cuja prova existente nos autos era de que foi utilizado no transporte ilícito, como já ressaltado, não havendo que se falar em restituição.

Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Réu Márcio da Silva Costa.

Verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra três condenações anteriores (fls. 80/84), de modo que uma delas será considerada na presente fase como Maus Antecedentes (11653-85.2013), por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, no entanto a quantidade do entorpecente apreendido, mais de trezentos quilogramas, justifica a elevação da pena base, a qual fixo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, que é específica e dupla (autos 498-46.2014 e 9993-66.2007, conforme fls. 80/84). Aqui, cedio que o Código Penal não estabelece limite mínimo e máximo para o aumento da reprimenda em casos de circunstâncias agravantes.

Por outro lado, esta julgadora não se escusa do entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há diferenciação entre a reincidência específica ou genérica no tocante à fração a ser aplicada em decorrência desta agravante, havendo consenso do montante de um sexto seja qual for a hipótese. Todavia, no caso em apreço estão presentes circunstâncias concretas que determinam o maior agravamento, tendo em vista tratar de duas condenações anteriores por prática da mesma natureza que a presente, tornando maior o grau de reprovabilidade da conduta.

Além disso, referido entendimento encontra eco em julgados proferidos pela Corte Bandeirante. Vejamos:

"Reincidente específico em relação ao tráfico de drogas, daí porque justificável o aumento na fração de 1/4, dada a maior reprovabilidade" (TJSP; Apelação Criminal 1501900-52.2019.8.26.0559; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

"Em que pese a lei não defina o percentual a ser adotado, esta Câmara vem reiteradamente optando por 1/5" (TJSP; Apelação Criminal 1502791-90.2020.8.26.0542; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e considerando ainda a incidência da atenuante da confissão, agravo em 1/8 (um oitavo) a pena anteriormente fixada, a qual passa ao montante 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Finalmente na última fase da dosimetria da pena, tratando-se de réu reincidente específico, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, "Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). Desta forma, torno a pena acima em concreto, por não vislumbrar a presença de qualquer outra circunstância modificadora aplicável.

A substituição da pena corporal por restritiva de direito resta afastada por ser o réu reincidente específico (artigo 44, inciso II, § 3º, do CP) e porque foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória

deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso VII, da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Réu Washington Mendes Chaves

Verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra duas condenações definitivas anteriores (fls. 100/103), de modo que uma delas será considerada na presente fase como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante na próxima etapa. Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, porém a quantidade do entorpecente apreendido, mais de trezentos quilogramas, justifica a elevação da pena base, a qual fixo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, não incidem causas de aumento ou redução de pena.

Finalmente, tratando-se de réu reincidente, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, "O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

No caso em apreço, trata-se de réu reincidente que foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP), o que afasta a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu permaneceu encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso V da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Réu Nicolas de Lima Nunes

Verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais (fls. 94/95) e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, cuja quantidade da substância apreendida será sopesada na derradeira fase, evitando-se inadmissível bis in idem. Nesses termos, fixo a pena base acima em 05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, considerando a primariedade técnica do denunciado e a ausência de indícios nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo possível a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº.

11.343/2006, no entanto, a redução deve ser modulada de acordo com a quantidade das drogas apreendidas. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. (HC 440.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) destaquei.

Destarte, diante de quantidade superior a 300 kg de maconha, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço) alcançando o montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena esta que converto em definitiva por não encontrar circunstância modificadora aplicável.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime.

Em relação à definição do regime inicial para o cumprimento da pena corporal, anoto que o tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a solidificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ficando afastada a incidência das disposições da Lei n.º 8.072/90. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu em sede de repercussão geral que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal"(RE 1052700, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgamento em 2.11.2017, DJe de 1.2.2018, Tema 972).

Importante ressaltar, outrossim, a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ no julgamento do HC 596.603-SP, que proibiu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena para o crime de tráfico na modalidade privilegiada.

Seguindo tais orientações e atenta aos princípios da individualização e da suficiência (artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal), verifico a expressiva quantidade de entorpecente traficado afasta a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu, razão pela qual fixo ao réu o regime intermediário - semiaberto.

Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu permanece encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 16% da pena, conforme art. 112, I, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial SEMIABERTO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra MARCIO DA SILVA COSTA, NÍCOLAS DE LIMA NUNES e WASHINGTON MENDES CHAVES, qualificados respectivamente a fls. 4, 5 e 6, para CONDENÁ-LOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

a) MARCIO DA SILVA COSTA à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

b) WASHINGTON MENDES CHAVES à pena de a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e

c) NÍCOLAS DE LIMA NUNES à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Os réus devem permanecer encarcerados, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade deles pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado, devendo ser ressaltado que no caso em apreço traficavam expressiva quantidade de maconha. Ademais, no caso dos réus Márcio e Washington, são reincidentes e com maus antecedentes, demonstrativo da evidência concreta de que pode reiterar na prática delitiva. Esses elementos denotam profundo envolvimento com práticas ilícitas e a persistência na conduta em questão apesar do esforço estatal para ressocializá-los. Não se deslembra, ainda, que fora fixado regimes prisionais para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, são incompatíveis com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada aos sentenciados.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência - Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomendem-se-lhes, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; c) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim e c) oficie-se ao SENAD, para que seja dada a destinação legal ao veículo apreendido nos autos, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas

processuais.

Expeça-se certidão de honorários oportunamente, se o caso.

P.I.C.

Ourinhos, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA